

1500107-10.2022.8.26.0580

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JONAS FERREIRA ANGELO DE DEUS

Comarca: Palmital

Foro: Foro de Palmital

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 01/06/2022

... paulista decidiu no mesmo sentido:

"Apelação - Tráfico de entorpecentes - Recursos defensivos - Nulidade - Ausência de autorização judicial para ingresso na residência - Denúncias anônima indicando que na residência ocorria tráfico de drogas - Fundada suspeita a justificar o ingresso dos policiais - Delito permanente, cujo estado de flagrância se perdura no tempo - Tese de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Palmital

Foro de Palmital

2ª Vara

Avenida Reginalda Leão, 1500, Palmital - SP - cep 19970-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500107-10.2022.8.26.0580 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500107-10.2022.8.26.0580

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Claudemir Goncalves Martins

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JONAS FERREIRA ANGELO DE DEUS

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo propôs a presente ação penal em face de CLAUDEMIR GONÇALVES MARTINS, nascido em 15/08/2002 e já qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Narrou, na inicial acusatória, que, no dia 27 de fevereiro de 2022, por volta das 18h05, na Rua J. Holmo, n.57, Jardim das Flores, nesta cidade e Comarca de Palmital-SP, o denunciado guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, 01 (um) invólucro contendo cocaína, na forma de crack, com peso total de 58g, com peso líquido de 55,2g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi preso em flagrante em 27/02/2022 (fl. 01), sendo decretada a sua prisão preventiva em 28/02/2022 (fls. 61/66).

O acusado foi notificado (fl. 131) e ofereceu defesa prévia (fls. 142/146).

A denúncia foi recebida em 26/04/2022 (fls. 205/206).

O réu foi citado (fl. 201).

Na fase instrutória, foram ouvidas cinco testemunhas e o réu foi interrogado (fls. 241/243).

Em alegações finais, o representante do Ministério Público pugnou pela procedência

do pedido formulado na denúncia. Requereu ainda: a) a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão da expressiva quantidade de droga encontrada; b) fixação de regime inicial fechado (fls. 254/258).

A Defesa, por sua vez, sustentou, em síntese: a) houve ilegalidade em sua prisão e no ingresso na residência, devendo ser absolvido; b) em caso de condenação, deve ser aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06; c) deve ser ficado regime aberto, substituindo-se a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos; d) deve ser concedida a gratuidade da justiça (fls. 262/271).

É o relatório.

Decido.

Não há matérias preliminares a serem apreciadas ou a presença de nulidade que deva ser conhecida de ofício, razão pela qual passo ao exame do mérito.

A materialidade delitativa foi comprovada por meio do auto de prisão em flagrante de fls. 01/02, dos termos de depoimentos de fls. 03/04, do boletim de ocorrência de fls. 25/27, do auto de exibição e apreensão de fls. 30/31, do laudo de constatação de fls. 32/34, do exame químico-toxicológico definitivo de fls. 110/112 e das demais provas colhidas sob o crivo do contraditório.

A autoria do crime, por seu turno, foi comprovada por meio da prova oral produzida nos autos.

Nesse diapasão, a testemunha André Luiz Maturano Ré, policial militar, disse que tiveram denúncia anônima de que o réu haveria acabado de chegar do Distrito de Sussuí com pedra grande de crack. Disse que passaram na residência dele, onde foi falado, oportunidade em que viram o réu, que saiu. Afirmou que não conseguiram realizar a abordagem. Informou que um tempo após conseguiram abordar o réu depois na Avenida Reginalda Leão. Mencionou que o réu afirmou que realmente tinha a droga. Informou que foram até a residência, que era dos sogros. Afirmou que foi franqueada a entrada pelos sogros. Disse que encontraram droga, duas balanças de precisão e faca com resquícios de droga. Mencionou que, ao consultarem, constataram que o sogro dele estava procurado por pensão e foi levado também à delegacia. Disse que já conhecia o réu, que já foi apreendido por assalto à mão armada quando menor de idade. Informou que foi pego em cima de moto com placa de outro veículo.

Acrescentou que não tinha informação anterior do envolvimento dele com o tráfico de drogas. Mencionou que a informação foi dada ao depoente. Disse que estavam parados próximo da Prefeitura, quando um senhor parou com carro e falou que o réu chegou com grande quantidade de drogas de Sussuí. Esclareceu que o informante descreveu Claudemir que mora atrás da delegacia. Informou que o que sabiam era que o réu morava com o sogro e a sogra e que namorava a filha deles. Confirmou que essa é a casa onde o réu residia, na rua José Olmo. Relatou que não havia a informação de ser destinada ao consumo ou a tráfico. Mencionou que a informação falava que a droga estaria na garagem da residência. Disse que, por isso, chegaram à residência, bateram palmas e explicaram aos sogros, que franquearam a entrada e olharam apenas a garagem, não olharam dentro da residência. Disse que a droga foi encontrada em caixa de papelão no alto, acondicionada cerca de dois metros de altura. Informou que foi o depoente quem encontrou. Mencionou que as balanças e a faca estavam junto, dentro da caixa. Informou que o réu estava na viatura. Afirmou que o réu já tinha falado que a droga era dele ao ser abordado na avenida e que não comentou sobre a destinação dos entorpecentes. Disse que recebeu a denúncia próximo da Prefeitura e que a pessoa não era conhecida do depoente. Relatou que não se recorda o horário, mas que era no horário da tarde. Informou que não se lembra do horário da abordagem. Afirmou que a denúncia não mencionava o veículo usado pelo réu, descrevendo apenas que ele tinha acabado de chegar de Sussuí com pedra grande de crack que estaria na garagem da casa onde ele residia. Acrescentou que foi dito apenas Claudemir que morava atrás da delegacia. Relatou que não sabe precisar a distância entre o local onde o réu foi abordado e a residência dos sogros. Afirmou que não encontrou nada de ilícito com o réu na avenida. Informou que é uma avenida e que sempre há alguém na rua. Disse que Jeferson e Juliana autorizaram a entrada, com nome e RG deles. Informou que a garagem é fechada com porta e os entorpecentes estavam do lado de dentro. Disse que o réu, na entrevista, afirmou que tinha a

droga. Confirmou que o réu teve motocicleta apreendida. Disse que o distrito de Sussuí fica cerca de 15 km de Palmital por estrada de terra. Relatou que não se recorda se o réu estava sujo ou não. Disse que o réu estava com a namorada no momento da abordagem.

A testemunha Vinícius Bastos Domiciano, policial militar, afirmou que participou da diligência. Disse que estavam próximo a prefeitura e que passou indivíduo que não se identificou e afirmou que o réu possuía entorpecentes na residência dele. Afirmou que realizaram uma diligência pelo local e visualizaram o réu, porém este se evadiu do local, não sendo possível a abordagem no primeiro momento. Disse que realizaram abordagem posterior do acusado próximo ao lanchódromo. Mencionou que o réu admitiu possuir droga na casa e que se deslocaram até a residência para verificar o fato. Disse que encontraram os sogros e pediram autorização e explicaram a situação. Acrescentou que eles autorizaram o ingresso e que foram localizados entorpecentes, duas balanças de precisão e faca usada para fracionar a droga, tendo sido tudo acompanhado visualmente pelos proprietários da residência. Disse que conhecia o réu dos meios policiais. Afirmou que ele já andou com moto adulterada. Informou que, quando menor, praticou delito de roubo. Mencionou ser novo na cidade, mas já ouviu comentários. Afirmou que já tinha ouvido que o réu praticava o tráfico de drogas. Esclareceu que já tinha informação há um ano, desde que foi transferido para o interior. Relatou que o réu não informou a destinação da droga, mas que seria muito difícil o consumo pela quantidade e pelo valor da mercadoria. Acrescentou que a pedra apreendida possui valor de cerca de R\$3.000,00 a R\$3.500,00. Afirmou que não tem informação se o réu trabalhava ou possuía alguma renda. Acrescentou que o informante relatou que seria Claudemir e que vindo de Sussuí com o material entorpecente, que estaria na garagem dos sogros dele. Afirmou que, a princípio, o réu deve ter utilizado algum veículo por dar de 15 a 18km de terra entre Palmital e Sussuí. Esclareceu que o informante não disse o modo como o acusado veio. Relatou que não foram encontrados objetos usados por quem consome a droga. Disse que foram encontradas duas balanças de precisão e faca com resquícios de drogas. Afirmou que o acusado não aparentava estar sob efeito de drogas. Informou que o depoente e seu parceiro receberam a denúncia. Relatou que a pessoa chegou de veículo e não se identificou. Disse que a denúncia foi aproximadamente às 15h, 15h30min. Informou que levou tempo até o início da diligência. Relatou que são dez, onze quarteirões entre o local da abordagem e a residência. Disse que nada de ilícito foi encontrado no momento da abordagem e que o réu estava apenas de posse do celular. Mencionou que, chegando à residência, entraram em contato com os sogros, que autorizaram a entrada e acompanharam a visualmente a revista, que foi realizada apenas na garagem. Acrescentou que foi André quem encontrou o entorpecente.

O informante Jeferson Brito Lopes afirmou ser amigo do acusado. Relatou que conhece o réu há um ano, desde que se relacionou com a sogra dele. Afirmou que o réu morava na mesma casa que o declarante. Informou que ele trabalhava com o irmão da Giovana e que fazia forro PVC. Afirmou que ele trabalhava todo dia e que não sabe a renda dele. Mencionou que não sabe se ele tinha veículo. Afirmou que não sabe se ele foi apreendido ou encontrado com moto. Relatou que estava na residência, pois mora com a mãe de Giovana. Afirmou que Juliana colocou filme para assistir e que dormiram. Afirmou que os policiais estavam abrindo e que chegaram entrando. Informou que assinou autorização. Mencionou que eles entraram e deram papel depois. Informou que entraram apenas na garagem. Afirmou que foi colocado para fora da casa. Mencionou que não conseguia ver a garagem. Disse que viu encontrarem, mas que saíram com as "coisas". Mencionou que eles saíram com a mão fechada. Disse que todos da casa tinham acesso e que não era guardado carro. Informou não saber se o réu era usuário de drogas. Relatou que, quando foi ver o que era no portão, um policial foi arrogante com o declarante. Disse que não viu o policial agredir fisicamente, mas que disseram que se fizesse algo bruto seria agredido. Relatou que o papel foi dado para assinar após a busca. Mencionou que Claudemir estava dentro da viatura. Afirmou que os viu entrando na garagem e saindo com algo na mão. Relatou que falaram que acharam drogas e duas balanças. Disse que viu quando levaram na delegacia. Afirmou que viu apenas na delegacia.

A informante Giovana Silvério de Oliveira afirmou que o réu é seu marido. Disse que a abordagem ocorreu no domingo. Informou que saíram e ficaram na rua no dia anterior até três horas da manhã. Disse que acordaram dez e meia no domingo. Relatou que ficaram em casa e decidiram almoçar no pesqueiro com casal de amigos, Bruno e Tiago. Informou que foram no carro deles e que ficaram até quatro e meia. Relatou que, depois da sorveteria, pegou copo de bebida e que chegou a força táctica, que os abordou e revistou seu marido. Informou que não acharam nada de ilícito com ele, mas o acusado foi colocado na viatura. Mencionou que estavam saindo quando chegou à residência. Disse que o réu ajudava seu irmão, que era vidraceiro. Informou que era empregado, ajudante de vidraceiro. Afirmou que não era registrado e que trabalhava por dia. Disse que ele ganhava cerca de um salário mínimo por mês.

A informante Juliana Cristiane Silvério afirmou que o réu é marido de sua filha. Disse que no domingo estavam em casa e que ao sair a polícia havia aberto o portão e estava dentro da garagem. Afirmou que eles falaram que haviam pego o réu, que havia falado que havia droga ali. Relatou que deram documento depois que disseram que encontraram droga. Mencionou que durou cerca de dez minutos. Afirmou que o réu não tinha veículo. Mencionou que o réu havia comprado no leilão e que a polícia havia pego. Afirmou que o réu tinha ido ao pesqueiro nesse dia. Relatou que sua casa tem grade na frente e portão da garagem de correr. Informou que estavam na sala. Afirmou que escutou barulho no portão da garagem. Disse que já tinham entrado no portão principal e que estavam dentro da garagem. Informou que o portão estava aberto. Relatou que não reparou se encontraram alguma coisa no local.

O acusado, por sua vez, em sede policial, afirmou que:

"Quanto aos fatos que lhe estão sendo imputados, informou que desconhece qualquer (sic) fato relacionado com a droga que os policiais militares afirmaram que encontraram na residência onde reside. Esclarece que quando foi abordado estava com sua esposa, em frente ao 'lanchódromo', tomando sorvete. Os policiais militares o levaram até a residência onde reside, não exibiram qualquer mandado judicial, o deixaram dentro da viatura, do outro lado da rua e, também, não visualizou a droga que os policiais militares afirmaram que encontraram. Por fim, informou que não é usuário de drogas." (fl. 06)

Judicialmente, ao ser interrogado, o réu negou a prática do delito. Relatou que os policiais lhe abordaram na avenida. Informou que pediram para o acusado parar e que foi abordado. Disse que pediram o endereço de sua casa e lhe perguntaram se havia droga, ao que respondeu que não. Informou que uma semana antes estava colocando forro na Fepasa. Afirmou que foi colocado na viatura e foi levado para sua casa, onde já havia viatura. Mencionou que os policiais disseram que estava preso e que descobriu o motivo na delegacia. Relatou que não viu os policiais encontrando a droga. Relatou que todos da residência tinham acesso. Informou que não é usuário de drogas. Relatou que não tem nada contra os policiais e que uma semana antes foi pego com moto comprada pela internet. Disse que fizeram o serviço deles e o liberaram. Afirmou que foi internado na Fundação Casa por assalto e ficou um ano internado. Disse que não teve outras passagens. Mencionou que tinha quinze anos à época. Relatou que nesse domingo acordou e apareceram Bruno e Tiago para ir a pesqueiro. Disse que foram a pesqueiro e depois passaram na avenida. Informou que foi comprar copo de açaí, quando apareceu viatura lhe abordando. Disse que foi revistado e que não falou que havia droga em sua casa.

A despeito da versão exposta pelo réu e dos argumentos apresentados por sua nobre Defesa técnica, o quadro probatório delineado acima permite a formação de juízo de convicção acerca da autoria e da materialidade delitiva, haja vista a comprovação de que o acusado guardava e tinha em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal, substância entorpecente.

Com efeito, os policiais militares ouvidos em juízo relataram, de modo uniforme, que, após o recebimento de notícia detalhada apontando a prática do crime e indicando ser o réu o seu autor, este foi abordado em via pública e admitiu a existência de drogas em sua residência, o que foi, em seguida, confirmado pelos policiais, que se dirigiram ao local e, com a autorização dos moradores, encontraram a substância entorpecente mencionada na inicial acusatória em local e

com natureza correspondente à descrição realizada por meio da notícia anônima. Ressalta-se que na situação dos autos, as palavras dos policiais apresentam confiabilidade, sendo certo que os relatos expostos pelos informantes ouvidos em audiência devem ser examinados com certa cautela, em razão do natural interesse em obter a absolvição do acusado, em virtude da relação de proximidade existente entre este e aqueles.

Além disso, não foram trazidos dados verossímeis que pudessem desabonar os depoimentos prestados pelos policiais militares e não se vislumbra que teriam qualquer motivo para prejudicar o réu.

Sobre o tema, inclusive, o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

"2. Esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese"(AgRg no AREsp 1686847/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020)

O C. Supremo Tribunal Federal também já asseverou que:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (HC 73518, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26/03/1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293)

Destaca-se ainda que não se vislumbra irregularidade no ingresso no domicílio por parte dos policiais militares, pois, além dos depoimentos dos militares acima exposto e do teor da declaração de fl. 35, que evidencia o consentimento dos proprietários da residência, o crime em apreço possui natureza permanente, prolongando, por conseguinte, a situação de flagrante e atraindo, nessa medida, a autorização prevista no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, mormente em face das fundadas razões para ingresso decorrente da notícia de crime formulada de modo anônimo e da admissão do acusado sobre a presença de drogas no local.

Em casos recentes, o e. Tribunal de Justiça paulista decidiu no mesmo sentido:

"Apelação - Tráfico de entorpecentes - Recursos defensivos - Nulidade - Ausência de autorização judicial para ingresso na residência - Denúncias anônima indicando que na residência ocorria tráfico de drogas - Fundada suspeita a justificar o ingresso dos policiais - Delito permanente, cujo estado de flagrância se perdura no tempo - Tese de nulidade afastada" (TJSP; Apelação Criminal 1500458-85.2018.8.26.0559; Relator (a): Juscelino Batista; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José do Rio Preto - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/05/2021; Data de Registro: 12/05/2021)

"Tráfico de entorpecentes - Crime permanente - Ingresso em residência - Mandado judicial - Desnecessidade - Nulidade inexistente;" (TJSP; Apelação Criminal 1500369-83.2020.8.26.0594; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bauru - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/05/2021; Data de Registro: 17/05/2021)

Destarte, a quantidade e a forma de armazenamento da substância apreendida - ainda não fracionada -, o valor da droga apreendida, o qual se revela condizente com o usualmente adquirido para consumo pessoal, a apreensão de faca contendo resquícios de drogas, bem como a localização de instrumentos costumeiramente empregados para a preparação dos entorpecentes para venda, quais sejam, duas balanças de precisão, permitem concluir, de modo cabal, que as drogas se destinavam ao comércio espúrio. Observa-se, ademais, que não houve a caracterização de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade em favor do acusado e que este era imputável na data do delito e

possuía consciência da ilicitude de sua conduta.

Frisa-se ainda a impossibilidade de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06, haja vista que os elementos probatórios produzidos indicam a mercancia espúria, consoante detalhado alhures, inexistindo, noutra banda, substrato mínimo a indicar que os entorpecentes apreendidos seriam destinados ao consumo pessoal.

A prova produzida não deixa dúvidas, portanto, de que o acusado praticou a infração penal descrita na inicial acusatória, devendo responder penalmente pela conduta praticada.

Reconhece-se, noutro giro, a incidência atenuante da menoridade relativa, porquanto o acusado era menor de vinte e um anos na data do fato (CP, art. 65, I).

Verifica-se também a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, pois a certidão de fls. 42/43 indica a primariedade do acusado e inexistem elementos indicativos de que o acusado integre organização criminosa ou se dedica a atividades criminosas, já que o mero cometimento de ação descrita no núcleo do tipo penal em questão não se mostra suficiente para afastar a aplicação da minorante em tela, consoante já decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça em caso quejando:

"1. Revela-se ilegal a não aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 à condenada primária e sem antecedentes criminais surpreendida na posse de pequena quantidade de entorpecentes - 4 gramas de crack e 46 gramas de maconha - quando a Corte a quo, com base na conduta criminosa que lhe foi atribuída e pela qual findou condenada, concluiu que fizesse da traficância sua profissão, sob pena de considerar toda e qualquer ação descrita no núcleo do tipo do art. 33 da Lei 11.343/06 uma situação incompatível com a aplicação da minorante em questão." (PEXT no HC 253.732/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 06/11/2013) .

Acrescenta-se, outrossim, que, embora o acusado já tenha sido condenado ao cumprimento de medidas socioeducativas pela prática de atos infracionais, a certidão de fls. 44/45 aponta que a extinção das últimas execuções de medidas socioeducativas ocorreu no início de 2019.

Dessa maneira, ausente proximidade temporal com o crime em tela, o qual fora praticado cerca de três anos depois, não há como se inferir a dedicação do réu às atividades criminosas, o que justifica a incidência da minorante em apreço, conforme entendimento pacificado pela Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça:

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. PLEITO DE AFASTAMENTO COM BASE EM ATOS INFRACIONAIS. PREVALECIMENTO DE ENTENDIMENTO INTERMEDIÁRIO. POSSIBILIDADE EM CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS, DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA DESIGNADA PARA REDIGIR O ACÓRDÃO. TESE NÃO APLICADA AO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS HÁBEIS A RECOMENDAR A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM, NO CASO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Consoante o § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena diminuída, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. Para que o agente possa ser beneficiado, é preciso preencher cumulativamente os requisitos.

2. Na esfera da Lei n. 8.069/1990, as medidas socioeducativas aplicadas em resposta a ato infracional cometido por adolescente possuem o objetivo de responsabilização quanto às consequências lesivas do ato, a integração social e garantia de seus direitos individuais e sociais, bem como a desaprovação da conduta infracional (art. 1.º, § 2.º, incisos I, II e III, da Lei n. 12.594/2012 - SINASE).

3. No entanto, apesar de a medida socioeducativa, impositiva e preponderantemente pedagógica, possuir certa carga punitiva, certo é que não configura pena e, portanto, não induz reincidência nem maus antecedentes. Nessa medida, é

incompatível considerar o registro de anterior ato infracional, na terceira fase da dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas, como elemento caracterizador da dedicação do agente a atividades delituosas, obstando a minorante, equiparando a conduta a crime hediondo e recrudesendo a execução penal.

4. Vale dizer, o registro da prática de fato típico e antijurídico por adolescente (inimputável), que não comete crime nem recebe pena, atingida a maioridade penal, não pode ser utilizado como fundamento para se deduzir a dedicação a atividades criminosas, e produzir amplos efeitos desfavoráveis na dosimetria e execução da pena.

5. No caso concreto, foi tida por inidônea a fundamentação que fez alusão genérica ao histórico infracional para concluir pela comprovação da dedicação às atividades criminosas, sobretudo porque nenhum outro dado foi extraído do conjunto probatório para respaldar a conclusão de que os agentes vinham se dedicando à atividade criminosa, o que tampouco foi possível identificar a partir da quantidade não expressiva de entorpecente.

6. No entanto, prevaleceu, no âmbito da Terceira Seção, para fins de consolidação jurisprudencial e ressalvado o entendimento desta Relatora para o acórdão, entendimento intermediário no sentido de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.

11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração.

7. Embargos de divergência conhecidos e desprovidos."

(EResp 1916596/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Rel. p/ Acórdão Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 08/09/2021, DJe 04/10/2021) (g.n.)

Impõe-se, portanto, a condenação do acusado pela prática da conduta acima delineada, razão pela qual passo à dosimetria das penas, em atenção ao previsto no art.68, caput, do Código Penal.

Na primeira fase do cálculo da sanção penal, em análise das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal e no art. 42 da Lei n. 11.343/06, observa-se que, embora a quantidade de drogas não seja exacerbada, a substância apreendida (crack) apresenta natureza especialmente lesiva, ao passo que as demais circunstâncias não lhe são desfavoráveis. Assim, exaspero a pena-base em 1/6 (um sexto), fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da reprimenda, presente a circunstância atenuante da menoridade relativa e em atenção ao disposto na Súmula n. 231 do c. Superior Tribunal de Justiça, atenuo a pena em 1/7 (um sétimo), resultando em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na última fase, devido à incidência da minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, diminuo a reprimenda em 2/3 (dois terços), de modo que a pena fica definitivamente fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Registra-se, por oportuno, que as circunstâncias previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/06 já foram apreciadas na primeira fase de dosimetria, o que impossibilita o seu exame nesta fase, como forma de se evitar a consideração das mesmas circunstâncias em duplicidade, conforme tese fixada pelo c. Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (Tema 712):

"As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena." (ARE 666334 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 03/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-084 DIVULG 05-05-2014 PUBLIC 06-05-2014)

No mesmo sentido, pronunciou-se o c. Superior Tribunal de Justiça:

"1. Constitui indevido bis in idem a valoração negativa de idênticos fundamentos - 'expressiva quantidade de drogas' - na primeira etapa da dosimetria da pena, para elevar a pena-base, e na terceira, para negar ou mesmo modular a fração da minorante do tráfico privilegiado." (EDcl no HC 648.275/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em

17/08/2021, DJe 20/08/2021)

Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal de um trinta avos do salário-mínimo vigente ao tempo do fato (Lei n. 11.343/06, art. 43), devido à ausência de maiores apurações sobre a situação financeira do acusado.

Estabeleço o regime inicial aberto, nos termos do art. 33 do Código Penal, tendo em vista a primariedade do acusado, as circunstâncias judiciais acima descritas e a quantidade de pena fixada, bem como o entendimento consolidado pelo c. Supremo Tribunal Federal (Tema 972) de que:

"1. É inconstitucional a fixação ex lege, com base no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal." (ARE 1052700 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 02/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-018 DIVULG 31-01-2018 PUBLIC 01-02-2018)

Presentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos (CP, art. 44, §2º), consistentes em (i) prestação de serviço à comunidade ou a entidade pública a ser definida na fase de execução, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação; e (ii) pagamento de prestação pecuniária, prevista no artigo 43, inciso I, do Código Penal, a qual fixo, considerando a condição financeira do acusado, em 01 (um) salário mínimo, em favor de entidade a ser designada na fase executória. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para condenar o réu CLAUDEMIR GONÇALVES MARTINS, como incurso no art. 33, caput e §4º, da Lei n. 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviço à comunidade ou a entidade pública a ser definida na fase de execução e pagamento de prestação pecuniária em 01 (um) salário mínimo, nos termos acima delineados, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário de um trinta avos do salário-mínimo vigente ao tempo do fato. Considerando o regime inicial acima fixado para o início do cumprimento da pena, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, a manutenção da prisão preventiva do acusado consistiria em medida desproporcional, uma vez que mais gravosa do que a reprimenda fixada na sentença. Por essa razão, revogo a prisão preventiva do acusado e concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se o respectivo alvará de soltura para que o acusado seja colocado em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. Em observância ao previsto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, esclareço que deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, pois se trata de crime de perigo abstrato, inexistindo vítima determinada.

Após o trânsito em julgado:

- a) oficie-se ao instituto de identificação do Estado;
- b) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para fins de cumprimento do previsto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal;
- c) expeça-se guia de execução definitiva.

Condeno o sentenciado ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, devendo o requerimento de concessão da gratuidade da justiça ser examinado na fase de execução, dada a possibilidade alteração na situação econômica do réu entre a data da condenação e a da execução do decreto condenatório, conforme já decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 1840436/MG, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020; AgRg no REsp 1857040/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/05/2020, DJe 18/05/2020).

Proceda-se, em relação à droga apreendida, conforme determinado no art. 72 da Lei n. 11.343/06.

Decreto o perdimento dos valores apreendidos em favor da União, nos termos dos artigos 63 da Lei n. 11.343/06.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Palmital, 01º de junho de 2022.



JONAS FERREIRA ANGELO DE DEUS  
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA